

1501454-47.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... que o acusado já foi condenado por tráfico e já praticou atos infracionais equiparados a tráfico anteriormente. Quanto à dosimetria, pede sejam consideradas na terceira etapa as passagens anteriores por tráfico de antecedentes e as circunstância referentes à quantidade e variedade de drogas, para fins de afastamento da minorante do artigo 33, §4º da lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501454-47.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501454-47.2021.8.26.0537 2021/001211

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JIVANILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

JIVANILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 21, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal porque, no dia 21 de julho de 2021, por volta das 13h30min, na Rua Uassari, número 100, bairro Campanário nesta cidade e Comarca de Diadema, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 52 (cinquenta e dois) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 22,61 gramas, 105 (cento e cinco) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 56,58 gramas, 19 (dezenove) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 59,93 gramas e 09 (nove) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como Skank, com peso aproximado de 2,67 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Dispensada audiência de custódia, em razão da Pandemia de COVID-19, com base do comunicado da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo editado em 17/03/2020, proferiu-se decisão convertendo a prisão em flagrante do réu em prisão preventiva (fls. 46/48). Mandado de prisão expedido às fls. 50 e devidamente cumprido às fls. 87.

Notificado (fls. 83), apresentou defesa prévia às fls. 93/94 e a denúncia foi

recebida em 22/09/2021 (fls. 95/96).

O réu foi citado (fls. 121), sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento que se realizou em 10/01/2022, de forma telepresencial, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 e resolução 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ocasião em que foi ouvida uma testemunha policial, interrogou-se o réu e procedeu-se com a gravação das alegações orais apresentadas pelo Ministério Público. À Defesa foi concedido o prazo de 05 dias para apresentação de memoriais escritos. Em alegações finais, a D. Promotora de Justiça requereu a procedência do pedido, condenando-se o réu nos termos da denúncia, posto que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovados. Aponta que a versão do acusado mostra-se inverossímil e isolada dos demais elementos de prova produzidos, e divergente com a versão apresentada à Autoridade Policial. Ressalta que o acusado já foi condenado por tráfico e já praticou atos infracionais equiparados a tráfico anteriormente. Quanto à dosimetria, pede sejam consideradas na terceira etapa as passagens anteriores por tráfico de antecedentes e as circunstâncias referentes à quantidade e variedade de drogas, para fins de afastamento da minorante do artigo 33, §4º da lei 11.343/06.

A D. Defesa, por sua vez, apresentou memoriais escritos (fls. 156/165) nos quais postulou a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ante a fragilidade do acervo probatório. Aponta que o testemunho do policial restou isolado nos autos e não se presta isoladamente a fundamentar uma condenação, por ter ele interesse em justificar suas razões em razão da função que exerce. Destaca ainda que a versão apresentada pela testemunha policial Gessé não foi ratificada em Juízo, e que há divergências entre as versões apresentadas em Juízo e em sede policial pela testemunha Felipe, no tocante à utilização de uma mochila ou de uma sacola pelo acusado, e também quanto aos tipos de droga que estavam em posse dele. Salienta que não há imagens da ação policial que permitam comprovar sua legalidade, a despeito de o governo do Estado de São Paulo fornecer câmeras que são anexadas às fardas dos agentes. Subsidiariamente, em caso de condenação, pede a fixação da pena base no mínimo legal, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais. Na segunda etapa, pede seja afastada a agravante de que trata o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, e que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, compensando-se ambas as circunstâncias, caso reconhecida a agravante, com aumento da pena em no máximo 1/6. Na última fase, requer a aplicação do redutor de que trata o artigo 33, §4º da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, salientando que a existência de processos em andamento ou processos que tratam da apuração de atos infracionais, por si, não constitui fundamento idôneo para afastamento da causa de aumento. Pleiteia ainda a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, com conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, computando-se no tempo da pena a ser fixada o período de tempo em que o réu permaneceu custodiado por este processo, para fins do quanto disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal. Por fim, requer seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante nos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitativa restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), laudo de constatação (fls. 29/32), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 150/152) e pela prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Ao ser ouvido em Juízo, o réu negou a prática do crime. Disse que, no dia, estava trabalhando e, por volta do horário de almoço, decidiu passar em casa para tomar um banho e ver suas irmãs, momento em que seu amigo Guilherme pediu que ele, acusado, fosse até sua casa levar umas roupas para ele. Quando estava retornando para o trabalho, foi para a casa de Guilherme para entregar as roupas. Quando estava de

saída, deparou-se com os policiais escondidos em um beco. Disse que ficou assustado e entrou novamente na casa de Guilherme, que morava em uma viela nas proximidades, mas os policiais os fizeram sair, levaram-nos para o outro lado da viela e, após feita busca pessoal na qual nada encontraram, perguntaram quem possuía passagem, ao que o réu respondeu que possuía. Os policiais então liberaram seu amigo e lhe perguntaram o que estava fazendo ali. Conta que então explicou aos policiais que havia apenas vindo trazer umas roupas e que estava trabalhando. Então, outros policiais surgiram e perguntaram ao policial que o havia abordado se era ele mesmo quem estava traficando e, ante a resposta afirmativa, jogaram uma sacola com as drogas em seu colo e o imputaram falsamente o tráfico de entorpecentes. Então a irmã e a mulher de seu amigo apareceram, e os policiais informaram que precisariam fazer uma revista na residência de Guilherme. Feita a revista, mesmo sem mandado, nada teria sido encontrado, porém os policiais insistiram que ele, acusado, estava traficando, e o algemaram, levando-o à Delegacia. Não conhecia os policiais antes dos fatos. Afirmar que seu amigo Guilherme não quis ir até a Delegacia. Confirma que já foi preso por tráfico. Na Delegacia, nega que tinha afirmado que estava trabalhando no tráfico como campana, e que os policiais lhe disseram que apenas deveria assinar um documento para que fosse liberado.

Tal versão, entretanto, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova, que se revelaram suficientes para demonstrar a prática do crime pelo réu. Com efeito, em depoimento bastante seguro prestado a este Juízo, a testemunha Felipe de Brito Rodrigues, policial militar, confirmou que estavam em região conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes, quando flagraram o acusado com uma bolsa. Afirmar que o réu então demonstrou nervosismo e saiu correndo, ao que a equipe saiu em perseguição, durante a qual o réu dispensou a mochila e ingressou numa casa, onde acabou preso, no telhado. Na mochila, foram localizados crack, maconha e cocaína, além da quantia em dinheiro, cujo valor não se recorda. O réu no momento da prisão apenas disse que estava traficando, sem maiores explicações. Não conhecia o réu antes dos fatos. Confirma que era o réu mesmo quem estava com a mochila. Não se recorda bem se era uma mochila ou uma sacola plástica. Conta que para abordar o réu, utilizaram de "elemento surpresa", e não pararam para observá-lo antes. Não avistaram o réu vendendo drogas para algum usuário, porém afirma que no local é comum a traficância. O patrulhamento foi feito com viaturas.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras do policial, que atuou de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhe depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando nas comunidades verdadeira "lei do silêncio", temendo sofrer represálias.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que o policial estivesse perseguindo o réu ou que tivesse qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e que sabe ser inocente. Ressalte-se que o próprio réu nada falou a esse respeito.

Assim, a credibilidade do testemunho do policial não pode ser afastada. Nesse ponto, ressalto que as divergências apontadas pela Defesa, em memoriais, entre o depoimento prestado em Juízo pelo policial e a versão apresentada na Delegacia em nada o comprometem como elemento de prova, posto que estão em harmonia no essencial.

Dessa forma, verifica-se que no dia dos fatos a equipe policial estava em patrulhamento quando avistou o réu em atitude suspeita, e optou por abordá-lo. Ao notar a presença dos policiais, o acusado então dispensou uma sacola que trazia consigo e correu, sendo perseguido pelos policiais que saíram em seu encalço. Na tentativa de fuga, o réu adentrou em um imóvel localizado em uma viela, nas proximidades da rua onde ele havia sido inicialmente avistado pelos policiais, os

quais o alcançaram ali e o detiveram. Com o acusado, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém na sacola dispensada por ele foram localizados os entorpecentes apreendidos nestes autos, de diversa natureza e expressiva quantidade (59,93g de maconha, 56,58g de crack, 22,61g cocaína e 2,67g skunk), embalados em várias dezenas de porções individualizadas, além da quantia de R\$ 8,00 em espécie. Tais circunstâncias evidenciam que, efetivamente, a droga encontrada pertencia ao réu e se destinava à entrega a consumo de terceiros, bem caracterizando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mostrando-se impossível, por consequência, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a prática do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Assim, não restou configurada nenhuma causa de exclusão de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, havendo provas suficientes para que seja condenado o réu nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal de 1988 e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta Maus antecedentes (fls. 36/38 e 77/78). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo a pena-base no piso legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda fase, trata-se de réu primário (fls. 36/38 e 77/78). Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa (réu nascido em 18/08/2000, com 20 anos de idade à época dos fatos), a qual não tem o condão de acarretar a redução da pena já fixada no mínimo legal, conforme súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Consigno, ainda, que em nenhum momento a ação do acusado foi favorecida pela situação de calamidade pública atualmente vivenciada no país para a prática do crime de tráfico, não podendo, portanto, ser considerada para o fim de agravar a pena. Veja-se a respeito:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. 1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito. 3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente. 4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos fundamentos declinados." (HC 654.255/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 07/06/2021)

Na derradeira etapa, deixo de reduzir a pena com base no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que, a despeito da primariedade do acusado, há indícios de que ele se dedica à prática de crimes, já que ostenta condenação anterior pela prática de tráfico de entorpecentes, ainda que sem trânsito em julgado. Além disso, ostenta passagem pelo Juízo da Infância e Juventude também por ato infracional equiparado a tráfico (como confessado e fls. 33) , e também trazia consigo quantidade razoável de entorpecentes, de quatro espécies diferentes. Tais circunstâncias apontam que o acusado se dedica a traficar drogas, não preenchendo portanto o requisito previsto no mencionado dispositivo legal para a concessão desse benefício. Assim, as penas ficam mantidas, em caráter definitivo, nos

patamares obtidos nas fases anteriores da dosimetria.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime SEMIABERTO, o qual se justifica, além da quantidade de pena, em razão da variedade de drogas, circunstâncias preponderantes nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, de forma a afastar a possibilidade de aplicação do regime mais brando, já que este não seria socialmente recomendável. Pelas mesmas razões, mostra-se impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77 e seguintes do Código penal. Impossível, ainda, aplicar disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde o flagrante até a presente decisão, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO JIVANILSON OLIVEIRA DOS SANTOS à pena de 05 (cinco) anos, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 90), observando-se o disposto no artigo 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, que não abrangem valores eventualmente já depositados nos autos.

Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, cabendo ressaltar que por ocasião da prolação da decisão que converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 46/48) já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à realização do laudo definitivo.

Com relação à quantia de R\$ 8,00 apreendida (fls. 26/27), decreto seu perdimento em favor da União. Preceda-se conforme as determinações do artigo 63 da Lei de Drogas, cobrando-se o envio do comprovante de depósito respectivo. Já a sacola apreendida deverá ser encaminhada para destruição.

Sentença não publicada em audiência. Intime-se as partes, fazendo-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA